

1500690-33.2021.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016);

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba-SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500690-33.2021.8.26.0126 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500690-33.2021.8.26.0126

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2094210/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 17195050 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 1114/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2094210 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO ARAUJO DO NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

KAIO ARAUJO DO NASCIMENTO e JOÃO VITOR SANTANA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial, em data incerta, os acusados se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o delito de tráfico de drogas. Consta ainda que, no dia 07 de abril de 2021, pela manhã, na Rua Sebastião Moreira Cesar, nº 598, Tinga/Centro, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, KAIO ARAUJO DO NASCIMENTO e JOÃO VITOR

SANTANA DOS SANTOS, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, traziam consigo, forneciam, guardavam e tinham em depósito 17 (dezesete) porções de Maconha, com peso total de 271,7g e 01 (um) tablete de Maconha, com peso total de 260,3g.

Segundo restou apurado, os custodiados se associaram para o fim de praticar, ainda que não reiteradamente, o tráfico de drogas nas imediações do bairro Jaraguazinho, trazendo consigo parte do entorpecente acima e mantendo em depósito a outra parte apreendida.

A Denúncia foi recebida 22 de abril de 2021 (fls. 112/115).

Os réus foram citados (fls. 137 e 140) e apresentaram resposta à acusação (fls. 151/158).

No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, bem como os réus foram interrogados, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, suscitou a nulidade das provas obtidas e requereu a absolvição dos réus. Ofertou teses subsidiárias.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 11) e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls. 26/29), autos de exibição e apreensão (fls. 30/32), auto de constatação preliminar (fls. 33/34), laudo pericial (fls. 130/132 e 213/215) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria está comprovada.

A testemunha e Policial Militar DIOGO RODRIGUES BITTENCOURT DA COSTA disse, na delegacia, que estava em patrulhamento pelo bairro Jaraguazinho, local dos fatos, quando se deparou com o indiciado JOÃO VITOR SANTANA DOS SANTOS em atitude suspeita, e o mesmo ao avistar a viatura demonstrou nervosismo, momento em que foi abordado pelos policiais militares. Que em revista na abordagem localizaram R\$30,00, trocados, uma bucha de maconha e um celular. Que JOÃO VITOR disse que estaria vendendo drogas e que venderia a bucha de maconha por 50 reais. Que JOÃO VITOR autorizou o acesso ao telefone celular, informando a senha, tendo o mesmo mostrado conversas relacionadas ao tráfico de drogas, dizendo que quem fornecia as drogas para a venda seria a pessoa de KAI0, informando o endereço do mesmo, momento em que policiais se diligenciaram à Rua Elvira Perpétua, 733 - Tinga. Que no local encontraram um indivíduo que informou que KAI0 teria se mudado para o bairro Jaraguazinho, na Rua Sebastião Moreira César, 598, onde de pronto se deslocaram a referida residência. Chegando no novo local, encontraram KAI0 no quintal da residência, onde o informaram que havia uma denúncia sobre tráfico de drogas, tendo o mesmo autorizado a entrada dos policiais e aberto o portão da residência. Kaio disse que havia drogas na residência, direcionando-os ao local exato onde as drogas estavam armazenadas, dentro do quarto de KAI0 e sua esposa. Que na residência também havia uma criança, filho do casal, uma faca e uma balança que seriam utilizadas para o tráfico de drogas. Que Kaio estava com um celular, fornecendo o

acesso ao mesmo e informando a senha do aparelho. Que JOÃO VITOR, KAI0, e sua esposa YANAÊ foram conduzidos a esta Delegacia de Polícia, juntamente com as drogas, valores em dinheiro, aparelhos de telefone celular, a faca, balança e uma bolsa onde estaria parte das drogas, para serem tomadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária.

Em juízo declarou que avistou um indivíduo de bicicleta que apresentou certo nervosismo após ver a equipe. Em abordagem pessoal encontraram com ele R\$ 30,00, uma porção de maconha e um celular. Indagado, JOÃO VITOR disse que fazia comércio dos entorpecentes, pegando a droga em porções maiores de KAI0. Pediram que destravasse o celular, para pesquisa, e na tela inicial tinha conversas sobre tráfico de drogas. Perguntaram onde morava KAI0 e ele informou que era no bairro Tinga. Foram até o local, um condomínio, onde havia um senhor na entrada, que, questionado, disse que KAI0 havia se mudado e informou o local onde KAI0 morava, no mesmo bairro onde o JOAO VITOR foi abordado. Pediram apoio ao sargento e foram até o local. Havia um casal no quintal, uma residência pequena com portão de grade. KAI0 de pronto se apresentou, e informaram-no sobre a denúncia. KAI0 confessou que traficava, abriu o portão com chave, levou os policiais até o quarto e mostrou os entorpecentes. A esposa de KAI0 ficou muito quieta. Havia um tablete maior de maconha e umas 17 porções já fracionadas, com uma balança e uma faca. A abordagem de JOAO VITOR foi motivada por seu comportamento nervoso e assustado. O local já era conhecido como ponto de tráfico. Não se recorda de já ter abordado JOAO VITOR anteriormente. Com JOAO VITOR havia uma porção de maconha, mas não soube precisar a quantidade. JOAO VITOR confessou que pegava porções maiores de entorpecentes do KAI0 e vendia. Perguntaram se o celular era produto de ilícito, ele disse que não; não tinha NF, pediram para consultar, e já apareceram mensagens sobre tráfico. Prontamente JOAO VITOR passou o endereço do KAI0; um morador informou que ele havia se mudado e disse que ele morava no Jaraguazinho. Não se recorda se tinha um adolescente perto, falou com um senhor, que informou o endereço do KAI0 precisamente, com rua e numeral. Chegaram com apoio do Sargento. Havia um casal no quintal com uma criança. KAI0 se apresentou e foi informado sobre a denúncia. A casa era pequena. KAI0 confessou que tinha drogas, abriu o portão e mostrou os entorpecentes no quarto. Quando abordaram JOAO VITOR estavam em uma viatura. Comunicaram apoio para ir até a casa do KAI0. A companheira de KAI0 ficou quieta e pegou a criança no colo. KAI0, no momento em que chegaram, não portava nada de ilícito. Pegou a chave dentro da casa e abriu o portão. Antes de abrir o portão ele já disse que possuía droga em casa. Em nenhum momento os acusados alegaram que eram usuários. A droga estava numa pochete em cima da cama no quarto, junto com a faca e a balança. Na hora em que estavam levando KAI0, chegou uma senhora e dois rapazes, que reclamaram um pouco. Acredita que ela era a mãe de um deles. Acredita que a senhora também apareceu na delegacia, mais tranquila. As porções na casa do KAI0 já estavam porcionadas, meio quilo de maconha aproximadamente. É costumeiro pedir apoio, sempre mais policiais do que pessoas abordadas.

A testemunha e Policial Militar MARCIO JOSE DOS SANTOS, que também participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega.

Relatou que abordaram JOAO VITOR, que portava no bolso uma porção de maconha, celular e trinta reais em dinheiro. JOAO VITOR confessou à equipe que traficava, e que pegava a droga do KAI0, indicando a moradia do KAI0. Foram até o local indicado, e moradores disseram que ele não morava lá mais. Foram até outro bairro, onde estavam um casal e uma criança. KAI0 confessou que tinha drogas em sua casa e franqueou a entrada; levou os policiais até o quarto do casal, onde encontraram uma balança, maconha e faca. KAI0 confessou que efetuava tráfico. Não chegou a dizer que vendeu a droga para o JOAO VITOR, mas no celular do JOAO VITOR tinha mensagens sobre os entorpecentes. JOAO VITOR ficou nervoso quando viu a equipe policial, por isso foi abordado. Com ele foi localizada porção de maconha, trinta reais e um celular, embalada num plástico transparente. Não se recorda da quantidade da porção

com o JOAO VITOR. Perguntaram a ele se o celular era de procedência ilícita; JOAO VITOR destravou o aparelho e tinha no aplicativo WhatsApp uma mensagem contendo informação sobre o tráfico. JOAO VIGOR informou que pegava os entorpecentes do KAI0 e deu o endereço no bairro Tinga. No portão do condomínio do local indicado um morador indicou que KAI0 não morava ali mais e informou o seu endereço. Não falaram com nenhum adolescente nessa residência. Não sabe dizer quem é esse morador. Chegando na casa do KAI0, havia um portão de ferro de onde dava para ver o quintal. Havia um casal no quintal. Esclareceram ao KAI0 a denúncia. KAI0 abriu o portão e disse que possuía droga em casa. Conduziu então os policiais até o quarto do casal onde foi encontrado o entorpecente. Isso durou uns 40 minutos aproximadamente, do Tinga ao outro bairro. Encontraram uma pochete com 17 porções de maconha, faca e uma balança de precisão. Os entorpecentes estavam em porções de vários tamanhos, embaladas em plásticos transparentes. Não se recorda a quantidade exata de porções maiores. A droga estava em cima da cama dentro da pochete. Foi apreendido também o celular. Não se recorda se pediram para desbloquear o celular do KAI0. O policial estava com a tarjeta de identificação no momento da abordagem. A esposa do acusado KAI0 manteve-se silente o tempo todo durante a abordagem. Não questionou sobre mandado de busca, apenas o KAI0. Apareceu uma senhora e dois indivíduos, entre eles um adolescente, quando estavam saindo para conduzir o acusado à delegacia. A mesma viatura conduziu a esposa do acusado, que foi apresentada à delegacia.

A testemunha Ynae Dauane Damasio Abranches, na delegacia, declarou que mora junto com KAI0 há aproximadamente seis anos, tendo um filho de 1 ano e 8 meses com ele; Que KAI0 é viciado em maconha e não sabia que o mesmo traficava drogas; Que não tinha conhecimento da quantidade de drogas guardadas por KAI0, tendo sempre visto pequenas quantidades para consumo e que a balança seria para KAI0 conferir o peso da drogas que comprava para consumo. Que veio da cidade de Paraty/RJ com KAI0 há aproximadamente 4 anos, pois naquela cidade o pai de KAI0, quando este tinha 12 anos, que também era usuário de drogas, foi assassinado, mas que até hoje sofria ameaças relacionadas ao pai.

Em juízo declarou que tinha acabado de acordar quando a policia os abordou. KAI0 apareceu na janela dizendo que tinha dois policiais no portão. Levantou, foi procurar a chave, e um dos policiais estava com arma apontada para KAI0 no quintal. O portão estava trancado com cadeado. Os policiais entraram, revistaram-no, e pegaram o celular dos dois. JOÃO VITOR não estava na casa. Conhece o JOÃO VITOR. Sabe que a droga ficava no guarda-roupa para consumo de KAI0, em pequenas porções. Os dois ficavam juntos fumando. Disse que no guarda-roupa a droga estava em pequenas porções. Não reconhece o tablete de maconha. Foi para a delegacia em outra viatura, depois que o KAI0 já havia sido conduzido. Os policiais pegaram o celular de sua mão. A abordagem policial ocorreu por volta das 9 horas da manhã. Quando saiu de sua residência um policial já estava armado, apontando na direção do KAI0, para que ele não saísse do quintal. Abriu o portão porque estava se sentindo ameaçado, pois um policial apareceu com uma ferramenta para cortar o cadeado do portão. Seu irmão mandou uma mensagem no celular, dizendo que tinha um amigo do KAI0 na casa dele, querendo saber onde eles moravam. Perguntou qual é o nome do amigo, ele responde JOAO e fala que está pedindo o endereço. E falou com o KAI0 que tinha um amigo dele na casa da sua mãe. Sua mãe chegou exaltada na sua casa, querendo saber o que tinha acontecido. Nessa hora o policial ficou bravo e levou a depoente para dentro da viatura e disse que ela ia se ferrar por causa da sua mãe.

Em seu interrogatório policial o réu JOÃO VITOR SANTANA DOS SANTOS, confessou os fatos que lhe são imputados neste procedimento. Disse que estava indo entregar droga que acabara de vender para o comprador não identificado quando foi abordado pelos policiais militares. Foi localizado em seu poder 30 reais em espécie e uma bucha de maconha. Franqueou aos policiais militares o acesso ao seu celular, inclusive fornecendo a senha (1937). Apontou de quem comprava as drogas. Na ocasião da abordagem apontou o fornecedor das drogas, pois os policiais disseram que iriam liberá-lo, o que não ocorreu. Disse que foi ameaçado pelos policiais.

Posteriormente na viatura foi à residência do comparsa Kaio, onde foi efetuada a prisão dele com a grande quantia de drogas apreendidas.

Em juízo negou os fatos. Disse que no dia dos fatos, por volta das 8:20 saiu de casa para fumar um baseado com KAI0. Próximo ao Shibata, viu uma viatura, não demonstrou nada. Os policiais deram a volta e foram atrás dele. Ele parou a bicicleta e os policiais o abordaram. Encontraram no bolso uma bucha de maconha; ele disse que era usuário e que tinha prova que trabalhava, e podiam ver no celular; os policiais viram mensagens. Ele disse que não vendia droga, mas os policiais ficaram acusando. Falaram que só queriam o cabeça da história e que ele seria liberado na delegacia. Levaram-no até um muro e o agrediram. O PM Diogo pegou o revólver, colocou na sua cintura e disse que se ele fosse homem era para matar os três policiais; em seguida, chegou reforço. Apontou a pistola para a cintura dele. Apertou o gatilho e engasgou e disse que ele deu sorte. Guardou a pistola no colete de novo. O policial Márcio veio abordá-lo na mesma sequência, puxou uma faca e foi pra cima dele. Acabou cortando o próprio dedo, ficou com medo e falou o endereço da casa do KAI0. Colocaram-no na viatura. Não sabia que KAI0 havia se mudado. Levaram-no até o local. Voltaram em cinco minutos e bateram nele. Saíram e foram ao novo endereço do KAI0 e entraram lá e não viu mais nada. Não comprou a droga do KAI0. Estava com a droga no bolso e ia chamar ele para fumar baseado no campinho. Nunca disse que estava indo entregar a droga na delegacia. Apenas disseram para ele assinar o documento na delegacia. Disse que tinha sim a Nota Fiscal do celular. Não tinha no celular nenhuma conversa com KAI0 sobre drogas. Ele estava de um lado da pista e o levaram para o outro lado na abordagem; havia gente passando, mas era um local mais escondido. Começaram a opressão após o desbloqueio do celular. Inexiste qualquer conversa sobre tráfico no celular. Indicou o endereço do KAI0 no Tinga. Ficaram lá mais ou menos 10 minutos. Não chegou a ouvir nada, estava trancado na viatura. Na casa do KAI0 também não ouviu nada. Apenas viu um policial retornando e pegando um alicate na viatura. Depois disso somente foi ouvido na delegacia. ninguém leu o depoimento na delegacia, só o mandaram assinar, não deixaram ler. Não teve audiência de custódia.

O corréu, em seu interrogatório em solo policial, KAI0 ARAUJO DO NASCIMENTO, confessou os fatos que lhe são imputados neste procedimento e disse que estava em sua residência quando os policiais militares encostaram com a viatura em frente à sua casa. Na ocasião franqueou a entrada aos policiais militares e apontou o local onde as drogas estavam guardadas. Disse que não é traficante, porém, eventualmente, em razão da necessidade, vende pequenas quantidades para ajudar no sustento da família. Em algumas oportunidades, cerca de dez vezes, já forneceu drogas para o comparsa João Vitor vender a terceiros.

Em juízo declarou que tinha um pedaço de maconha em casa; deixava os pedaços separados para fumar após o serviço. Nunca traficou. Estava no quintal de casa fumando, quando sua esposa gritou do quarto dizendo que o irmão dela queria falar com ele, dizendo que tinha um amigo na porta da casa dele chamando. Os policiais apareceram de fora da rua, apontando arma, perguntando o nome dele, dizendo que ele estava preso. Avisou a esposa e ela trouxe a chave. Perguntou onde estava o mandado. O PM Diogo falou que ia buscar o mandado e apareceu com um alicate de cortar cadeado. Então ele abriu o portão, foi revistado. Os policiais pegaram o seu celular e o de sua esposa. Os policiais perguntaram onde estava a droga. Dentro de sua mala de viagem, pois tinham acabado de se mudar, mostrou a droga que possuía, que era para uso, para que não precisasse ficar indo em biqueira. O tenente apareceu e começou a gravar, mandando-o falar que a droga era dele se não ia levar seu filho para o Conselho Tutelar; então ele falou que a droga era dele. Pegava a balança para ver se tinha mesmo a quantidade que ele comprava. Cada porção possuía mais ou menos 10 gramas, 4 pedaços embalados, para um mês, aprox. 270 gr. Joga bola com o irmão do JOAO VITOR. Não tinha trocado mensagem com JOAO VITOR nesse dia, só uma mensagem de bom dia que recebeu dele. Pegaram o celular dele assim que entraram no quintal, mandaram desbloquear e não tinha nada. Não chegou a informar

seu endereço para o seu cunhado; ligou para ele por WhatsApp e ele disse que tinha um amigo dele chamado JOAO VITOR na porta querendo saber onde ele morava e ele não informou o endereço. Respondeu que ia até lá após cuidar do passarinho. Dez minutos depois o policial apareceu na porta da sua casa. A droga estava dentro da mala, ele indicou que os entorpecentes estavam dentro da mala, que também continha uma roupa. A balança e a faca estavam na porta do meio, dentro do guarda-roupa. A droga foi pesada dentro da casa, pegaram uma bolsinha de esmalte da sua mulher para isso. Tinha um pedaço maior e quatro pedacinhos cortados para usar naquela semana. Na delegacia os policiais leram o termo para ele, e mandaram-no assinar, mas não deu tempo de ler tudo antes de assinar. Não teve audiência de custódia. Só soube na delegacia que o JOAO VITOR estava indo para sua casa.

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar os réus pelo delito de tráfico de drogas.

Inicialmente, afasto a alegação de inobservância da inviolabilidade de domicílio do acusado Kaio. Isto porque, a partir dos relatos dos policiais tanto em solo policial quanto em juízo, infere-se que estes adentraram à residência do réu após indicação do endereço por JOAO VITOR, que informou aos policiais de onde retirava os entorpecentes que vendia. Além disso, a alegação foge ao narrado em solo judicial, sob o crivo do contraditório, pelo próprio corréu KAI0, que disse ter franqueado a entrada em sua residência, o que também havia informado em solo policial. Porém, em juízo, convenientemente alterou seu depoimento para incluir suposta coação na conduta dos policiais ao chegarem em sua residência, o que não veio acompanhado de provas ou mesmo indícios.

Ressalte-se que a jurisprudência entende ser viável a busca domiciliar em casos de crimes permanentes sem mácula ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e

penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016);

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). V - Do contrário, devidamente analisado o pleito na origem, o eventual acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido". (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Assim, pautado por tais entendimentos jurisprudenciais, afasto a tese de violação à inviolabilidade de domicílio, mormente levando-se em consideração que, de fato, o acusado estava em posse de grande quantidade de entorpecentes no interior da residência vistoriada.

Quanto à alegação de nulidade das provas obtidas por coação no acesso ao celular, é preciso esclarecer que nenhum dado de mensagem de aplicativo foi colacionado aos autos, justamente por não ter sido relevante, a título de prova, para a configuração da conduta delitiva por parte dos corréus. Isso porque, JOAO VITOR foi quem indicou o nome e o endereço do comparsa KAI0, e um terceiro, desconhecido, foi quem os levou até a casa dele. Em outras palavras, foi a confissão informal do corréu JOÃO VITOR que desencadeou a continuidade da abordagem policial, e não eventuais acessos ilegais a celulares.

O conjunto probatório pesa em desfavor dos acusados. consigne-se que o depoimento da companheira de KAI0 em juízo foi tomado sem o compromisso legal de dizer a verdade, dada a relação estabelecida entre ambos. Diversamente, os policiais, agentes de segurança depuseram em juízo sob as penas da lei, sabedores de seus deveres e das consequências de sua violação. Além disso, afirmaram desconhecer os acusados dos meios policiais, e não logrou a Defesa apresentar evidências de que a sua conduta, ou mesmo o seu depoimento, foi orientado em sentido diverso da verdade, em dissonância com a realidade da dinâmica dos fatos ocorridos. Ainda, o relato de ambos os agentes foi unísono e harmônico, e não se afastou da narrativa apresentada meses antes em solo policial. Por fim, a apreensão verificada do auto de fls. 30/32 é compatível não apenas com o relato dos agentes de segurança, mas sobretudo com o depoimento do próprio corréu KAI0, que confessou manter em casa, dentro de uma mala, a quantidade aproximada de 270 gramas de entorpecente.

Embora o corréu KAI0 afirme a propriedade da droga, nega que realizava a traficância. Porém, a forma de acondicionamento e os petrechos apreendidos em conjunto com os entorpecentes evidenciam a destinação ao comércio ilícito. Não convence a narrativa de que a balança encontrada servia para que o acusado confirmasse a quantidade mensal que adquiria da droga para consumo pessoal. Isso porque, conforme auto de fls. 30/32, os entorpecentes foram encontrados em 17 porções, o que é próprio do comércio ilícito, em conjunto com dinheiro, faca e balança de precisão.

Não bastasse, a quantidade mesma apreendida é absolutamente incompatível com o uso para consumo pessoal. Em que pese a ausência de fixação legal de critérios quantitativos para configuração do porte para consumo pessoal, o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 dispõe que “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se valido de estudos técnicos e mesmo do direito comparado para melhor definir o cenário que leva à tipificação do art. 28 da referida lei. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar no HC 159.731/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso (DJe 06/08/2018), in litteris:

“Com efeito, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão de cúpula da Justiça portuguesa – apoiando-se na legislação mencionada e, notadamente, na Portaria nº 94, de 26/03/96, do Ministério da Justiça e da Saúde (que define os limites máximos 'para cada dose média individual diária' referente a plantas, substâncias ou preparações de consumo mais frequentes) –, tem entendido, em diversos julgados, que 'os limites quantitativos máximos para cada dose média individual diária de heroína e cocaína são, respectivamente, de 0,1 e 0,2g' (Processo nº 98P1103, de 02/12/1998, Rel. VIRGÍLIO OLIVEIRA, v.g.), sendo certo que, tratando-se de maconha (“cannabis sativa L.”), esse limite é de 2,5g. Cabe assinalar, finalmente, por necessário, considerando o que determina a Lei nº 30, de 29/11/2000, que dispõe sobre o regime jurídico do consumo de estupefacientes em Portugal, que, para efeitos penais, o consumo médio individual diário há de ser projetado para um período de 10 dias, a significar, portanto, que a quantidade diária constante do Mapa anexo à já referida Portaria nº 94/96 deverá ser multiplicada por 10 (heroína, 1g; cocaína, 2g; e maconha, 25g), do que resultará o limite máximo a que alude o art. 2º do diploma legislativo ora mencionado, cujo teor é o seguinte: 'Artigo 2º Consumo

.....
..... 2 - Para efeitos da presente lei, a aquisição e a detenção para consumo próprio das substâncias referidas no número anterior não poderão exceder a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias.'”

No mais, a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, porque inexistente qualquer elemento para considerar suspeito ou equivocada. E mais, diante da prática adquirida com a profissão por eles desempenhada, são capazes de apontarem fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito para elucidarem o acontecido, só deles conhecida, que culminam por trazerem a certeza do cometimento imputado.

Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-los, o depoimento deles “podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

No mesmo sentido: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável

eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Por outro lado, quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, das provas amealhadas ao longo do inquérito e dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, não há como inferir, com a necessária certeza, o vínculo de estabilidade e permanência necessários a respaldar uma segura condenação, não havendo prova de materialidade da existência de associação criminosa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018).

E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré."(STF - HC: 124164 AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Condenação confirmada, quanto ao primeiro crime, dado o firme conjunto probatório. Valorização do depoimento policial. Associação afastada, ante a ausência de comprovação de sua estabilidade e permanência. Absolvição quanto a tal delito. Penas reduzidas, com abrandamento do regime prisional. Parcial provimento ao apelo da defesa e não provimento ao recurso ministerial". (TJSP; Apelação Criminal 0000021- 93.2019.8.26.0556; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara -

3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021); "REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Pretensão de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que foi abordado com droga em frente ao imóvel. Ingresso na residência autorizado pela corre, que era esposa do peticionário. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo rime de associação ao tráfico de drogas à corre". (TJSP; Revisão Criminal 0010326-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021).

Destarte, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre os réus. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda. Assim, apesar da existência de indícios, tais indícios não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe.

Assim, o que se depreende do conjunto probatório e prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é, neste aspecto, harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, os réus adquiriram, venderam e tiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, os entorpecentes descritos na denúncia.

Portanto, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Réu KAIO ARAUJO DO NASCIMENTO: